论文翻译——Rising Above Liability: The Digital Services Act As A Blueprint For The Second Generation Of Global Internet Rules

Martin Husovec

引用： Martin Husovec, *Rising Above Liability: The Digital Services Act as a Blueprint For the Second Generation of Global Internet Rules*, 38 Berkeley Technology Law Journal 883 (2023).

摘要

二十五年前的 1998 年，美国国会为全球互联网监管制定了一份蓝图。《数字千年版权法》（DMCA）第 512 条认识到，用户生成内容对大多数数字服务至关重要，并向部分服务提供者提供了以特定条件为前提的事前责任豁免。这一最初仅限于版权领域的有条件豁免制度，很快在 2000 年通过欧盟的《电子商务指令》（ECD）被扩展为一套全面、横向适用的规则体系——该体系近期已更新为《数字服务法》（DSA）。

过去二十年的经验在很大程度上验证了 DMCA 所确立的有条件豁免机制，证明其作为规制支撑全球思想、商品与服务交流的互联网通信的一种可行基础方案是有效的。然而，这种有条件豁免模式也有其局限性：它并非为应对新兴复杂挑战而设计。《数字服务法》则是首个全面尝试为依赖用户生成内容的数字服务构建“第二代规则”的立法。与以往局限于特定领域的举措不同，DSA 采取了一种广泛适用的横向方法。

DSA 要求国家与非国家机构均在一定程度上参与其中，其制衡机制方能有效运作；同时，DSA 的部分解决方案可能“过于欧洲化”。尽管如此，DSA 背后所体现的原则仍可能对其他司法管辖区具有借鉴意义——甚至包括美国。目前正在制定脱欧后自主监管框架的英国，也仍在沿用与 DSA 相似的一些核心原则。

I. 介绍

二十五年前的 1998 年，美国国会为全球互联网监管制定了一份蓝图。《数字千年版权法》（DMCA）第 512 条认识到，用户生成内容对大多数数字服务至关重要，并向部分服务提供者提供了以特定条件为前提的事前责任豁免。这一最初仅限于版权领域的、具有条件性的豁免制度，很快在 2000 年通过欧盟《电子商务指令》（ECD）被扩展为一套全面、横向适用的统一规则体系——该体系近期已更新为《数字服务法》（DSA）。这两大司法辖区的做法激励了世界上许多其他国家开始采纳类似的“有条件豁免”制度——即只有在服务提供者知晓他人

行为的前提下，才可能因其未采取行动而承担相应法律责任。

与 1996 年通过的《通信规范法》（CDA）第 230 条（§ 230）这位“年长的姐妹”不同，DMCA 第 512 条并未被广泛认为是“创造了互联网”的关键法律。然而，仔细审视便会发现：尽管 CDA 第 230 条或许仍在美国内部维系着我们所熟知的互联网法律生态，但真正驱动全球互联网运行的却是 DMCA 所确立的模式。对于许多国家而言，CDA 第 230 条为应用层服务所提供的那种近乎绝对的豁免，在宪法或法律文化上难以接受；相比之下，DMCA 提供的有条件豁免则更具可接受性。因此，这种 DMCA 式的有条件豁免正越来越多地被纳入双边贸易协定之中。如果未来国际社会真能就平台责任问题实现协调统一，这种有条件豁免模式很可能成为主流。

在欧洲，有条件豁免在数字市场发展的早期阶段发挥了关键作用，帮助各成员国在统一规则下凝聚共识。欧盟方案的巧妙之处在于：它没有试图在各国尚未统一的国内法领域逐一寻求妥协，而是聚焦于制定一个“放之四海而皆准”的折中标准，要求所有成员国的各类法律领域中的责任规则向这一单一标准靠拢。（*欧盟倾向于统一规则，而非差别化处理。*）《电子商务指令》第 4 条大幅简化了 DMCA 第 512 条中关于豁免的复杂机制，剔除了其中棘手的技术细节。这使得科技公司只需遵守更为严格的美国版权法规，即可同时享受欧盟《电子商务指令》制度下的保护。实践中，DMCA 所确立的详细“通知—删除”操作流程，由此成为全球事实上的标准。

过去二十年的经验在很大程度上验证了 DMCA 的有条件豁免机制，证明其作为规制支撑全球思想、商品与服务交流的互联网通信的一种可行基础方案是有效的。然而，该模式也有其局限性：它并非为应对新兴复杂挑战而设计。首先，许多当今的问题在当时尚不为人知或未被充分讨论；其次，彼时只有极少数人使用互联网，即便使用，互联网也远未成为人们生活的核心部分。2000 年《电子商务指令》通过时，全球互联网普及率尚不足 7%。（*现在这个机制出现问题的原因，一方面，当时有些问题就没讨论清楚；另一方面，网络世界发生了巨大变化。*）

到 2016 年，欧美社会对数字服务的主流看法开始发生转变。欧盟法院（CJEU）新创设的“被遗忘权”迅速兴起，对搜索引擎向个人承担责任提出了更高要求。Facebook 在缅甸因内容审核严重缺位而酿成的人道危机，暴露了平台在利润较低市场长期投入不足所带来的严重风险。2016 年美国总统大选前夕，社交媒体内容审核问题不可避免地被高度政治化。与此同时，欧洲社交媒体深陷移民危机漩涡，公众既展现出前所未有的组织化支持，也爆发了大量有毒的仇恨言论。很可能正是在此时，欧洲各国政府开始质疑自律是否仍是合适的路径，并逐渐意识

到：有条件豁免模式为平台留出的自由空间，亟需通过新的监管加以填补。（*传统的自我监管模式失效的事例，让欧盟觉得这种自我监管模式不再是一种有效的正确做法，应当加强监管。*）

《数字服务法》（DSA）正是首个全面构建“第二代规则”的尝试，旨在规制那些依赖用户生成内容的数字服务。与以往局限于特定领域的举措不同，DSA 采取了一种广泛适用的横向方法。其制衡机制的有效运作，有赖于国家与非国家机构的共同参与；同时，DSA 的部分解决方案可能“过于欧洲化”。尽管如此，DSA 背后所体现的原则仍可能对其他司法管辖区具有借鉴意义——甚至包括美国。目前正在制定脱欧后自主监管框架的英国，也仍在沿用与 DSA 相似的一些核心原则。

笔者希望，这些高层次原则能够成为自由民主国家之间就如何最佳规制用户生成内容服务展开对话的基础。毕竟，如果上世纪 90 年代末的欧洲人能够简化并扩展美国规则以契合自身目标，那么今天，其他国家或许也能以同样方式借鉴欧盟的新一代规则。政策的互操作性对于维系一个真正全球化的通信网络依然至关重要——正是这一网络，正在为人类带来前所未有的福祉。（*本文考察 DSA 能否有潜力成为全球范围内的下一代互联网规则。*）

II. 从 DMCA 到 DSA

对用户生成内容服务的欧洲监管显然受到美国法律的启发。在本节中，我首先简要说明这是如何发生的，然后阐述为何尽管如今存在诸多争议，但附条件免责（conditional immunity）这一做法在过去二十年中可以说已得到验证。

A. 责任豁免的简史

与同类中的首个责任豁免条款——即《通信规范法》（CDA）第 230 条——不同，后者在当时并未引起太多利益相关方的关注，[19] 而《数字千年版权法》（DMCA）第 512 条则是内容产业与科技公司之间艰苦谈判的产物。[20]

关于服务商版权责任的争论，因克林顿政府信息基础设施特别工作组于 1995 年发布的《白皮书》而变得激烈。该《白皮书》援引了美国法院此前就电子公告板作出的两项早期判决，[21]以支持其观点。<u>《白皮书》将包括互联网接入服务商在内的服务商承担严格直接版权责任视为既定事实，并认为“现在就减轻任何类型服务商的责任还为时过早</u>。”[22] 该报告隐含地鼓励原告对所有服务商——而不仅仅是电子公告板——进行试探性诉讼。1995 年，山达基教会在美国一家地区法院起诉了另一家电子公告板运营商以及一家互联网接入服务商 Netcom。[23] 虽然法院很快裁定公司不承担直接且严格的侵权责任，但<u>它确立了</u>

基于知情的间接侵权责任仍是一种可行选项。[24] Netcom 案无疑向电信公司——一个成熟的行业——发出了警报，使其意识到潜在的责任风险，尽管该案结果对其有利。[25]

这些公司最终游说国会，要求将 Netcom 案的原则编纂入 DMCA。[26]

在第 104 届美国国会未能通过《白皮书》的提案后，[27] 于 1997 年 1 月开始的新一届国会希望能在对立利益之间迅速找到解决方案，以成功实施世界知识产权组织（WIPO）《互联网条约》。[28] 在立法过程中，责任豁免成为整部立法得以通过的前提条件。[29] 正如参议院司法委员会报告所指出的，尽管该问题“在 WIPO 条约的实际条款中并未明确涉及，但委员会同情……服务商希望在此领域澄清法律的愿望。”[30] 当时人们普遍认为，“若不澄清其责任，服务商可能会犹豫是否对互联网速度和容量的扩展进行必要投资。”[31]

司法委员会的报告最初仅包含对“单纯传输”（mere conduits）的责任豁免。[32] 经过服务商与内容权利人之间为期三个月的直接谈判后，最终达成包含四项责任豁免的妥协方案——即**传输、缓存、托管和信息定位工具**——才得以实现。[33] 该妥协文本已于 1998 年 6 月被纳入众议院商务委员会的审议中，[34] 该委员会指出：[35]

第二编保留了服务商与版权所有者合作检测并处理数字网络环境中发生的版权侵权行为的强烈激励。（鼓励服务商与版权所有者合作。）同时，它为服务商就其活动中可能发生的侵权行为所面临的法律风险提供了更大的确定性。

DMCA 于 1998 年 10 月签署成为法律。国会“非常清楚其他国家会以美国立法为范本。”[36]

在欧洲，欧盟委员会于 1996 年 10 月向欧洲议会和理事会发布了一份通讯文件，解释称服务商需要法律保障才能恰当地在在线市场中运营。该通讯文件指出：[37]

互联网接入服务商和托管服务商在使用户获取互联网内容方面发挥着关键作用。然而，不应忘记的是，内容的主要责任在于作者和内容提供者。因此，必须准确界定责任链条，以便将非法内容的责任归于其制造者……法律可能需要修改或澄清，以协助那些主营业务是向客户提供服务的接入服务商和托管服务商，在审查指控与责任暴露之间找到一条可行路径。

两年后，欧盟委员会提出了《电子商务指令》草案。其第四部分包含了三项责任豁免——传输、缓存和托管。当时，仅有两个欧洲国家设有责任豁免制度。德国于 1997 年 7 月通过了两项横向责任豁免规定[38]（称为 IuKDG），瑞典则于 1998 年 5 月通过了一项关于电子公告板的法律。[39] 德国新法与 DMCA 均对“提

供他人信息的接入”与“提供空间”的服务作出了基本区分。因此，与 CDA 第 230 条不同，IuKDG 和 DMCA 均根据服务商与用户行为的接近程度来区分责任豁免。作为远端促进者的传输服务商获得了最广泛的豁免，而更接近用户的托管服务商则被赋予了以知情为基础的更为谨慎的豁免。就适用范围而言，德国法律似乎更为宽泛，因其扩展适用于所有“被提供使用”的服务。[40] 相比之下，§512 则聚焦于特定的技术功能——传输、缓存、存储和信息定位工具。

《电子商务指令》第四部分的主要灵感来源是 DMCA 第 512 条和 IuKDG 第 5 条。委员会从 DMCA 借鉴了三项责任豁免，并从 IuKDG 借鉴了横向适用的方法。与美国版权法规不同，《欧盟》提案并非出于实施 WIPO《互联网条约》的需要，而是源于欧盟在互联网发展初期希望建立一个无边界的内部市场的愿望。因此，美国在互联网版权问题上新近达成的妥协被扩展适用于所有法律领域。

欧盟委员会的提案于 2000 年 6 月获得通过。委员会的做法沿用了美国对服务类别的定义，因此可以说缩小了可依赖附条件免责的服务范围。例如，德国的规定本可轻松涵盖信息定位工具，而后者并未获得任何明确的豁免。[41] 2002 年，《电子商务指令》在十五个欧盟成员国成为法律，两年后又适用于另外十个新加入的成员国。截至目前，《电子商务指令》和《数字服务法》（DSA）适用于全部 27 个成员国。《数字服务法》作为一项欧盟条例，可直接适用，无需各国进行本地转化。英国脱欧后，至今尚未废除其对《电子商务指令》责任豁免条款的实施，且截至 2020 年底之前的欧盟判例在英国法院仍具约束力。[42] 英国目前正在制定自己的一套在线安全规则，以补充现有的豁免制度。[43]

尽管欧盟与美国法律在条文表述上的差异并非微不足道，但它们在很大程度上是可以调和的。[44] 一般而言，可以说欧盟简化了 DMCA，但也省略了其中一些关键组成部分。特别是，欧盟省略了对信息定位工具的责任豁免以及 DMCA 中关于禁令救济的详尽条件；后一省略成为重大分歧点。根据欧盟法律，只要符合“具体”监控的概念，禁令原则上不受限制。[45] 相比之下，DMCA 则以大量条件对禁令加以限制。[46] 因此，虽然根据 DMCA 第 512 条，所有预防性禁令——例如强制部署过滤器或网站屏蔽——实际上都不可能实施，但在《电子商务指令》第四部分下，它们很快成为欧洲诉讼努力的主要驱动力。[47] 最终，欧盟法院（CJEU）允许成功提起诉讼的原告寻求禁令，迫使服务商承担更多识别侵权内容的责任。[48]

在美国和欧盟引入责任豁免显然是出于相同的理由：通过提供更大的法律确定性来鼓励投资。因此，法律体系可以“在审查指控与责任暴露之间找到一条可行路径。”[49] 这一问题在不同法律领域中的紧迫程度有所不同；然而，在当时，一些科技公司的首席执行官因传播色情内容而在刑事诉讼中被判刑，这种担忧显

然并非无端夸大或小题大做。[50] 欧盟日益增多的国内判例被认为既过于不可预测，又过于繁琐，无法为这个充满前景的新环境提供可靠的法律框架。由于用户生成内容对数字通信网络如此核心，责任问题就是互联网规制的问题。The liability question was the question of internet regulation.（*在平台内容治理问题上，通过侵权法来规制。*）

B. 责任豁免与互联网的特殊性

法律在保障互联网的形态和结构方面发挥着关键作用。互联网作为一个网络的去中心化特性，与其促进其运行的主体所适用的责任制度密不可分。若没有法律的善意，就不会有我们今天所知的互联网。在一个技术促进去中心化但法律却提供反去中心化激励的假设世界中，理性的行为人不会在缺乏编辑控制的情况下创建空间或工具。对他人行为的责任制度是一个关键的激励因素。除非立法机构希望重新设立编辑角色，否则某种形式的附条件免责是必要的。

欧盟针对大多数托管用户生成内容的服务的计划是，要求受害者使用非司法性的通知—删除机制，并在可能的情况下依靠包括法院在内的当局的帮助。这种混合路径虽然比 CDA 第 230 条所基于的免责框架对受害者更为慷慨，但却限制了受害者和国家解决任何社会问题的能力。但这样做是有充分理由的：为了维持去中心化通信网络所带来的益处。通过遵守责任豁免，各方都承诺自我约束，以促成一个所有人都能从中受益的环境。这正是数字社会契约的本质。

相比之下，严格责任要求全面控制，而此类法律规则将给社会带来极高的成本。打个比方，如果印刷商对其为他人印刷的所有内容承担严格责任，他们就必然需要先阅读并审查所有要印刷的内容。结果将是印刷变得极其缓慢且昂贵，人们将越来越难以利用它来分享思想。

美国最高法院、欧洲人权法院（ECtHR）和欧盟法院在其人权判例中均已承认此类责任与言论自由之间的联系。[51] 这些最高法院为负责管理略超 10 亿人口的立法机构设定了规制用户生成内容服务的界限。[52] 目前，在大西洋两岸，服务商对用户生成内容承担严格责任都被视为不可想象且从根本上违宪的。美国和欧盟法院一致继续倡导“媒介特定”[53]或“分级且差异化”[54] 的规制方式，区别于对编辑媒体的规制。例如，尽管欧洲人权法院的判例法较为复杂，[55] 但它明确指出：“通知—删除机制在许多情况下可作为平衡所有相关方权利与利益的适当工具。”[56]

对互联网作为媒介的不同对待，并非源于对新技术的玫瑰色、天真的热爱。[57] 这归结为美国法官 Dalzell 在 1996 年所称的“互联网通信的特殊属性”，即它“是迄今为止发展出的最具参与性的大众言论形式”。[58] 欧盟法院将互联网

称为“个人行使其表达与信息自由权的主要手段之一”，[59] 并支持欧洲人权法院的观点，即“用户生成的表达活动”是“行使言论自由的前所未有的平台”。[60]

对 1990 年代末的 Dalzell 法官及其同僚而言，这些“特殊属性”是指发言者和读者的极低准入门槛，从而带来“令人惊叹的多样化内容”和“所有希望在该媒介中发言的人均可获得显著的接入机会”。[61] 对 2010 年代初审视这一问题的欧洲顶级法官而言，互联网的特殊属性在于：其“可及性”；其“存储和传播海量信息的能力”；其支持“用户生成的表达活动”的能力；以及其在“促进信息普遍传播”方面的作用。[62]

任何豁免自然都会被怀疑是立法对产业的偏袒。而且责任豁免当然可以以不同方式设计。然而，人们早已认识到，以 DMCA 为蓝本的责任豁免，与普通责任原则的常规适用相比，并不一定是重大的责任减免。[63] 正如佐审官 Jääskinen 所指出的，“这些条款更应被视为对现有法律的重述或澄清，而非对其的例外。”[64] 当我们查看 DMCA 第 512 条的文本时，这一点也很明显：该条文纳入了美国版权间接责任的诸多要求。[65] [1] 因此，尽管《电子商务指令》和 DMCA 中规定的附条件免责可能会带来一些变化，但通常并非重大的责任减免。在禁止一般性监控方面，互联网例外主义的论点稍显更强。然而，其最强的正当性在于防止对个人及其内容的无差别监控，而非作为保护服务商免受成本增加的规则。[66] （*禁止事前的一般性监控，是出于公法上的要求，而非出于成本的考量。*）

有人可能会反驳说，因此责任豁免并非必要，因为法院在多年诉讼后通过简单适用一般法律，最终会逐步得出正确的解决方案。虽然无法用反事实加以证明，但许多国家早期的责任历史[67] 以及大量近期判例法不一致的例子表明，立法的清晰性具有独特价值。例如，尽管欧洲人权法院近期关于责任的判例法原则上不允许各国大幅偏离基于知情的托管服务商豁免，但该法院显然无法制定出一个可预测的测试标准，而是在不断制造无数新的、细分的判例法。[68] 似乎习惯于进行细致权衡的法官们对制定清晰明确的规则兴趣不大。倘若欧盟成文法当初没有如此清晰，人权法几乎不可能提供可预测性。

C. 第二代规则的必要性

过去二十年勾勒出了诸多亟需解决的社会挑战，包括：儿童保护；仇恨言论或恐怖主义问题；以及旨在破坏我们民主制度根基的颠覆性活动。所有这些问题都因互联网作为媒介的“特殊特征”而加剧：缺乏编辑审核、极低的准入门槛（包括无处不在的零成本服务）、传播速度与规模惊人、广泛的社会与地理包容性，以及通信的韧性。因此，全球各地的监管机构正合理地考虑如何应对这些挑战。

---

[1] Compare Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984), with Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).

当责任豁免条款的明确立法目标本就是制定不完整且非限制性的规则，以允许这一媒介蓬勃发展时，仅仅诉诸现有的“数字社会契约”显然已不足够。某些利益相关方倾向于将责任豁免视为对未来任何规制的神奇限制，这种看法误解了其核心贡献。其关键作用并非阻止新规则的出台，而在于保留一套足以赋能的规则框架。在任何联邦制体系中，联邦层面的责任豁免通过优先于（preempting）各州或国家层级的立法实验，有助于协调全国性或地方性法律。这正是此类规则在美国和欧盟所具有的附加价值。然而，这并不意味着这些规则必须一成不变。事实上，欧盟和美国的经验均表明，联邦立法机构若无法更新联邦规则，可能导致各州自行试探其边界。[69]

此外，各种社会挑战所带来的损害及其受害者呈现出不同形态。有些损害因服务的设计而被放大；有些则由他人造成，仅因平台缺乏干预而得以助长。部分受害者缺乏维权资源，而另一些则资源充足；有些人能利用技术发现自身权利被侵犯，而其他人则不能。

在《数字服务法》（DSA）出台之前，《电子商务指令》（ECD）第 4 条将所有这些问题留给了自律机制或各国自行探索。然而，要有效规制一个全球性网络，监管行动必须足够重大，才能引起全球性企业的重视。例如，尽管欧洲已有三十年的数据保护立法，但直到 2016 年通过《通用数据保护条例》（GDPR），才真正使相关法律引起所有人的关注。

横向适用的责任豁免——如《数字服务法》第二章（原《电子商务指令》第 4 条）所规定的——旨在为言论和市场创造喘息空间，同时确保受害者权利可获执行，但它们并未针对具体挑战提供解决方案。第一代规则——即《通信规范法》第 230 条、《数字千年版权法》第 512 条以及《电子商务指令》第 4 条——均存在同样的不足：它们在协调预期、鼓励投资方面表现出色，却未能提供解决伴随这些服务使用而涌现的广泛社会问题的有效工具。

欧盟的《数字服务法》（DSA）正是如何在不损害互联网去中心化本质的前提下更新“数字社会契约”的一个范例。DSA 重申了附条件免责规则的民主正当性，甚至在边缘处对其有所扩展。因此，服务商对用户生成内容的责任基本未发生改变。[70] 真正发生变化的是：当企业就他人内容或行为作出决策时，其所面临的监管预期；以及对于某些服务商而言，在设计数字服务时所需考量的因素。这些公司通过监管机制向公众负责。然而，此类监管是专门为其量身定制的。监管不再将用户生成内容服务强行塞入不合适的既有法律类别，而是根据其规模和技术功能，为其设立专属的监管类别。

III. DSA 的两大支柱

《数字服务法》（Digital Services Act，DSA）包含两大核心支柱：（1）内容审核中的正当程序要求；以及（2）服务商的风险管理义务。

内容审核被界定并规制为一种决策过程，该过程源于服务商对责任豁免（例如托管豁免）的依赖。风险管理则聚焦于服务的系统与产品设计，要求服务商考量其广告基础设施、推荐算法及其他系统所带来的更广泛影响。

下表概述了 DSA 项下的所有主要义务。

规则的两极	技术行为	公司或服务规模	DSA 施加的主要的合理注意义务
内容过滤/审核 moderation	·传输 Conduit ·缓存 ·托管 Hosting	所有规模的公司	·联络点或法律代理人 ·清晰的条款和情况
		中型规模以及更大的公司	·内容过滤/审核报告
	·托管	所有规模的公司	·通知提交规则 ·对决定的理由说明 ·向主管部门通报犯罪行为
	·在线平台（托管服务的一种子类）	中等规模以及更大的公司	·优先处理可信的举报者 ·防范滥用的措施 ·内部的申诉机制 ·外部的申诉机制 ·广告与推荐系统的透明度
风险管理	·在线平台（托管服务的一种子类）	中等规模以及更大规模的公司	·对少数群体的保护 ·暗黑模式 ·交易平台中“了解你的客户”的义务
	·非常大的在线平台（VLOPs） ·非常大的在线搜索引擎（VLOSEs）	4500 万平均月活跃用户，不考虑公司的规模或营业额	取决于欧盟委员会的委任： ·风险评估以及对产品的所有设计特征进行审计 ·增强版的数据访问，供研究者来研究风险 ·危机反应机制 ·特别的广告营销的透明度 ·对于推荐系统的选择权 ·内部的合规官员

A. 内容审核

《数字服务法》（DSA）承认，私营公司所作的内容审核决定可能对个人的生计及其分享和接收他人信息的自由产生重大影响。过去十年表明，企业并不总是愿意在内容审核决策上投入足够资源，尤其是在较小国家或市场中。欧盟立法机构的解决方案是对作出此类内容审核决定的程序进行规制。

内容审核规则必须清晰且可预测（第 14(1)条），且决定必须基于既有的政策（第 14(4)条）。广泛类型的内容审核决定均须履行个别化说明义务（第 17 条）并提交年度透明度报告（第 15 条）。每一项决定都必须提供免费的内部申诉机制（第 20 条），并可能诉诸外部争议解决机制（第 21 条）。此外，许多要求被有意设定得较为宽泛：通知系统必须“用户友好”（第 16(1)条）；决定须“及时、勤勉、非任意且客观地作出”（第 16(6)条）；执法实践必须“适当顾及所有相关方的权利与合法利益”（第 14(4)条）。

上述条款为内容审核的程序层面设定了规则。关于可接受内容或行为的基础性合同规则仍由平台自行制定。然而，平台的规则制定空间因程序上的限制而受到间接约束。由于必须事先披露其规则（第 14(1)条），平台不得事后追溯变更政策，亦不得在现有规则之外凭空创设制裁措施（第 14(4)条）。平台仍可根据自身偏好，在非法内容之外通过合同进一步限制言论；但必须以非任意、非歧视的方式适用这些规则。任何合同性政策都将由庭外争议解决机构进行解释，而此类机构不得考虑任何形式的“秘密规则手册”。

这清楚表明，DSA 并未剥夺平台在内容审核方面的全部裁量权。它通常不限制平台依据其社区准则禁止何种合法内容——这项权力仍由平台保留。因此，如果平台不满意庭外机构对其规则的解读，它们可以修改规则并使其更加明确。但一旦将规则白纸黑字写明，就不得在不实际修改的情况下主张相反含义。DSA 仅限制某些明显不公平的政策（第 14(4)条），而这类政策很可能已违反消费者法等其他明确的法律禁令。（*DSA 的规定更多是对规则制定、规制适用中的程序性约束，实质性的规则由平台自行决定。新类型的“自我监管”？*）

这些程序性保障的目标，是将内容审核过程纳入一种更严谨的“编排”，以更好地反映内容审核决定对个体的实际影响。具体程序规则与宽泛的规范性期望相结合，旨在为标准制定提供基础，同时为内容审核决策树立“北极星”。对个人而言，这些规则赋予了比单纯依赖市场所能提供的更为可信的正当程序权利。

学者如 Douek 批评此类监管性的正当程序要求是一种不必要的“程序剧场”

（process theatre）[7] [22]，认为它无法解决根本问题，犹如“用茶匙从一艘正在沉没的船上舀水”[7] [3]。但这是否是正确的评论？首先，对受影响的个体而言，哪怕只有一线希望能让其申诉获得妥善解决，也足以构成设立这些机制的理由。这一理由并不会因其个人纠纷无法解决更大系统性问题而削弱。（*难以解决系统性问题的理由并不能削弱个案救济性机制的必要性。*）其次，DSA 试图将个人纠纷的维度转化为更广泛的学习来源（这一点为 Douek 所推崇），（*通过个案纠纷来获取更多的信息，提供给监管者、立法者、法官。*）并以此作为压力来提升程序的整体质量（*个案作为压力，促使解决系统性问题。*）[7] [4] [3]。最后，对于超大型在线平台而言，内容审核仅是其整体风险管理的一部分。

B. 风险管理

DSA 的第二大支柱是风险管理，包含一系列针对企业如何设计其产品及其他“幕后”流程的规则。与英国即将出台的《在线安全法案》（Online Safety Bill）[7] [5] 不同，DSA 在立法上明确根据服务的规模或影响力来分配责任。

只有被称为“在线平台”的数字服务——即以向公众分发用户生成内容为主要功能的服务——才需承担风险缓解义务[7] [6]。由微型和小型企业运营的平台（即员工少于 50 人或年收入低于 1,000 万欧元者）[7] [7] 无需履行任何风险管理义务。其背后的逻辑是：权力越大，责任越大。在风险管理框架下，平台被分为两类：

・较低层级：中型及以上企业，须遵守有限且具体的规则，主要涉及产品设计实践；

・较高层级：在欧盟拥有超过 4,500 万月活跃用户的在线平台或搜索引擎，须遵守一套更广泛且更具弹性的规则：即一般性风险管理义务。

较低层级的企业需要考虑其产品设计如何保护未成年人，以及防范操纵性和侵扰性做法（即所谓“暗黑模式”）。较高层级的企业除上述要求外，还需承担更多义务。这些特定企业被视作准公共广场——众多欧洲人在此聚集交流。经国家指定后，它们须就民主制度与个体所面临的相关风险（包括对人们自由与福祉的风险），与欧盟委员会及各国监管机构展开特别监管对话。鉴于这些利益难以清晰界定，其适用范围极为宽泛。

在 2023 年春季的第一轮指定中[7] [8]，以下数字服务被列为超大型平台：

・社交媒体：Instagram、LinkedIn、Pinterest、Snapchat、TikTok、Twitter、

---

[2] Evelyn Douek, *Content Moderation as Systems Thinking*, 136 HARV. L. REV. 526, p.577 (2022).

[3] 参见《数字服务法》第 21 条 2022 O.J. (L 277) against the background of a lab experiment concerning ADR system as a solution to rational bias against over-blocking. Lenka Fiala & Martin Husovec, *Using Experimental Evidence to Improve Delegated Enforcement*, 71 INT'L REV. OF L. & ECON. (2022), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144818822000357.

Facebook、YouTube

・电商平台：阿里巴巴、速卖通（AliExpress）、亚马逊商店（Amazon Store）、Booking.com、Google Shopping、Zalando

・应用商店：Apple App Store、Google Play

・其他：Google Maps、维基百科（Wikipedia）

・搜索引擎：Bing、Google Search

新施加的风险管理义务显然意在通过立法，在责任豁免之外，为这些服务附加关于信任、安全与公平的社会责任。

风险管理源于两项认知：第一，设计对任何生态系统的健康至关重要。这一观点因 Francis Haugen 揭露 Facebook 内部文件而得到强化[79]，其揭示了内容放大机制如何鼓励特定行为。第二，监管机构与平台之间长期存在信息与资源不对称，现实地决定了平台应承担寻找新解决方案的主要责任。（*委托、自我监管的原理。*）

DSA 的义务更多聚焦于所建立的流程或系统。然而，如下所述，这说起来容易做起来难。近年来，许多学者倡导某种“系统性监管方法”[80][4]，但具体方案差异显著。

一个尤其有影响力的概念来自 Lorna Woods 与 William Perrin 的提案，该提案启发了英国《在线安全法案》(OSB)。他们主张采用“安全设计”(safety by design)方法，描述如下[81]：

“监管机构应被赋予充分的自由度，以保持其方法的相关性与灵活性。我们建议监管机构采用类似于治理污染的‘减害’方法：就危害达成测试标准，执行测试，造成危害的公司投资以降低测试所得的危害水平，再次测试以确认投资是否有效，必要时重复此过程……监管机构随后将与最大型企业合作，确保其有效衡量了危害，并公布减害策略，以应对已识别的风险并缓解已发生的危害。”

该模型的框架——包括将其置于法定“注意义务”（duty of care）之下[82]——要求重新分配对个体伤害的责任。这进而引发对推荐系统和产品设计功能的监督，这些功能会改变用户行为，包括用户发布何种具体内容。尽管 Woods 与 Perrin 坚称其方法不会导致内容规制[83]，但他们也设想监管机构可预防性地限制“有害行为”[84][85]。因此，该方法几乎不可避免地触及环境的实质——即用户互动的基本规则。

相比之下，Evelyn Douek 的提案同样以系统为中心，但路径截然不同[86]：

“它不关注个别案件中的下游结果，而是聚焦于内容审核中关于设计与优先级的上游选择——这些选择设定了下游典型案件可能发生的空间边界……并且，

---

[4] For an overview of (mostly) U.S. scholarship, see Kate Klonick's response to Douek, supra note 72. Kate Klonick, Of Systems Thinking and Straw Men, 136 HARV. L. REV. 339, 347 (2023).

通过强调程序问责而非追求某种理想言论环境的实质性构想，该方法在政治上更具可行性，宪法脆弱性也更低。”

因此，她所称的“实质中立方法”（substance-agnostic approach）[8] [7] 更为有限，因为它允许企业在合法范围内试验任何内容政策。然而，该方法似乎聚焦于对“放大机制”（amplification）的规制，而正如 Keller 所指出的，放大机制本身也并非总能真正做到实质中立[8] [8] 。

在任何风险管理体系中，实质与程序之间的关系最为棘手。首先，任何试图处理“风险”或总体“有害行为”的方案都无法忽视：在用户生成内容服务上，用户所说或所做仍是关键风险因素。尽管服务设计可能鼓励某些行为，但无论是否被鼓励，此类行为总会以某种形式持续存在；通常，此类服务上的风险较少源于纯粹的非人为外部因素。

管理群体风险往往需要告诉个体必须如何行为。若监管机构将某些非法用户表达的发生率纳入指标，此类政策的合法性是明确的——立法机构已认定该行为非法，监管机构仅在执行合规。然而，若监管机构对某些合法表达施加相同指标，则很容易演变为对人们言论边界的管控——即对其通信内容的审查。对用户表达施加直接配额，若推至逻辑终点，意味着告诉某些人他们不能说什么。

无论是处理“危害”还是“风险”，关键试金石在于：谁来设定通信内容的边界？（*谁有能力、正当性来设定这个边界？*）

全面风险管理方法赋予监管机构最广泛的权力，可要求企业说明其服务设计如何影响平台上发生的行为。监管机构可观察、比较、分析，并要求企业作出改变，包括施加针对“问题”用户行为的定制化标准或配额，无论该行为是否合法。监管机构的权限由此延伸至“合法但恶劣”（lawful but awful）的内容，并使其成为替代立法机构、划定言论自由边界的“代理立法者”。（*可能的设定者：监管机构*）

有限风险管理方法同样关注可能诱发各类风险的系统设计，但在赋予监管机构（机构）权力以重新定义哪些合法个体行为应被配额禁止或压制之前止步。该方法承认，监管机构不具备议会的合法性。议会应继续负责设定非法通信内容的界标。若某类风险或危害特别严重，议会可进一步移动界标[8] [9] 。因此，监管机构对合法内容的要求仅限于那些通过赋予用户选择自由来维护其能动性的解决方案；此类方案主要通过赋能或重新设计用户的选择架构来实现。

可以说，《数字服务法》采纳的是有限风险管理方法。DSA 并未明确解决欧盟委员会是否可在风险管理策略中要求提供商修改其关于“合法但有害内容”

的合同标准的问题[90]。然而，在缺乏明确法律授权的情况下，委员会若试图压制特定合法表达，可被认为违反法治原则[91]。英国《在线安全法案》目前也正朝 DSA 的方向调整[92]，尽管其最初提案可能导致全面风险管理路径[93]。而澳大利亚 2021 年《在线安全法》则走得更远，允许监管机构要求删除“合法但恶劣”的内容[94]。

有限风险管理方法可通过公共抗议活动中的风险管控类比得到最佳阐释。设想一场反对移民政策的公共集会在城市街道举行。平台的角色可类比为抗议活动组织者[95]。

DSA 将欧盟最大的服务指定为受控的公共空间；它要求其设计者（即平台）分析因聚集人群而产生的风险，并在必要时干预。在此类情境中，国家与平台各自扮演什么角色？

国家可对组织者和抗议者施加安全措施，以保护他们免受他人伤害，也保护他人免受其伤害；并防止对人身、财产或商业造成损害。物理安全措施有助于言论自由，因为它们使每个人在表达观点时感到更安心。为此，监管机构可要求组织者采取各种安全措施，特别是预防抗议者或反抗议者的非法行为，包括禁止过度干扰或制造噪音。

然而，超出非法表达方式之外，监管机构不得控制谁可以发言或抗议、使用何种标语或口号、或在何处展示。当然，组织者可基于自身动机，在非法之外自行施加更严格规则。

现在设想这场集会有两支执法队伍，分别身穿红蓝夹克。红衣执法者代表国家，仅可在抗议者违反“红线规则”（即立法机构已确定为非法的行为）时介入。蓝衣执法者由组织者雇佣，类比于内容审核员。因组织者希望举办一场家庭可参与的合法集会，故要求所有参与者遵守其基本规则。这些“蓝线规则”不同于红线规则，允许组织者更早干预——例如，可规定禁止使用带有亵渎语的标语，因其可能引发非法行为。

出于效率考虑，国家会期望蓝衣执法者也执行红线规则。这类似于平台日常所进行的委托执法（即删除非法内容）。但红衣执法者不得执行蓝线规则。蓝线规则类比于平台为吸引用户和广告商而自愿采纳的合同性自我约束。红衣执法者不能以组织者自设的亵渎语禁令为由终止抗议或逮捕抗议者。要正当化此类干预，监管机构必须严格依据红线规则。逻辑上，他们也不能指示组织者应采用何种蓝线规则，因为这是立法机构的特权。不过，国家可要求那些接近冲突升级边缘的抗议者采取额外措施，以保护旁观者免受暴力伤害。

DSA 所定义的超大型在线平台（VLOPs）和超大型在线搜索引擎（VLOSEs）持续管理着庞大的人群。因此，它们必须定期评估风险，向审计机构提交报告，

并在审计机构不满意时采取后续行动。整套文件档案随后提交欧盟委员会进行最终评估，并向公众公开以供审视与批评。

IV. 新一代规则的原则

在读者已熟悉《数字服务法》（DSA）各项规则的基础上，我想提炼出若干界定其监管思路的核心原则。正如 Daphne Keller 所指出的："美欧监管路径的差异不应阻碍我们在平台规制的其他功能性层面寻求共识。"[96] DSA 蕴含丰富洞见，但要真正理解其内在逻辑，必须超越字面表述，深入"引擎盖之下"审视其设计思想。在我看来，以下五项原则可从 DSA 中提炼而出，并可作为立法者设计新一代规则的"共同基础"：[97]

问责，而非责任（Accountability, not liability）

规制的横向性（Horizontality of regulations）

责任共担：人人有责（Shared burden: everyone is responsible）

用户赋权（Empowerment of users）

生态系统解决方案（Ecosystem solutions）

A. 问责，而非责任

作为用户生成内容的促进者，平台不应被要求承担传统出版商（如报纸）那样的责任 liability 负担。尽管其内容审核功能在某些方面类似准编辑行为，但互联网的特殊属性——包括无需编辑审批、低准入门槛、惊人的传播速度与规模、广泛的社会与地理包容性，以及通信的韧性——要求建立不同的法律制度。对他人行为所产生的法律责任设定合理的豁免，是用户生成内容服务得以存续并发挥互联网独特优势的基本前提。

与其制定可能削弱这些优势的限制措施，不如聚焦于如何使平台的商业运营与社会最优实践相一致，从而最大化个体自由——即让企业对公共利益更具问责性（accountability），而非直接承担法律责任（liability）。

在 DSA 出台前，大多数相关法律试图通过以"连带责任"威胁平台来影响其行为。[98] 除少数领域（尤其是欧盟的知识产权法[99]）外，法院通常面临二元选择：要么施加全部责任及其后果，要么完全否认责任并确认豁免。DSA 终结了这种非此即彼的局面。立法机构设立的独立监管期望为法院和监管机构提供了第三种选项：违反这些期望将触发独立的执法机制，而非导致责任豁免失效。（*监管直接介入了，原来是通过要求其承担民事责任来威胁。*）

这类似于银行通常不对客户非法金融交易承担民事责任，但仍可能因未采用适当的反洗钱流程而被问责并处以罚款。

DSA 几乎完整保留了既有责任豁免。《电子商务指令》（ECD）第 4 条被纳入 DSA 第二章。其创新之处在于第三章所创设的新型监管义务——“尽职调查义务”（due diligence obligations）。这些义务与第三方内容的法律豁免无关。正如 DSA 序言第 41 条所指出：“尽职调查义务独立于中介服务提供者的责任问题，后者需另行评估。”违反尽职调查义务将触发 DSA 设想的独立执法体系，不会引发针对个体损害的海量索赔潮。其目标是改进企业用于内容审核或整体风险管理的系统与程序。（*行政监管+民事责任*）

举例说明：在美国版权法下，根据 DMCA 第 512(i)条，若平台未能终止重复侵权者的账户，将丧失责任豁免，从而可能对用户利用其服务实施的版权侵权行为承担连带责任。而在欧盟版权法下，此类失职不影响责任豁免。但在 DSA 生效后，未能终止重复侵权者账户可能构成对 DSA 第 23(1)条的违反，可被公私主体追究，即便责任豁免依然有效。两种情形的后果截然不同。

DSA“问责而非责任”的设计并非自动选择。在立法过程中，欧洲议会曾强烈主张将责任豁免与尽职调查义务挂钩——即任何违反 DSA 第三章的行为都将导致豁免失效。这种“以合规为前提”的模式存在于印度《信息技术法》（2000 年）第 79 条[100]，也被 Danielle Citron 教授提议作为美国修订 CDA 第 230 条的方案[101]。在此类体系下，责任豁免将成为一种“奖赏”或“特权”，仅授予完全遵守 DSA 的平台。随着尽职义务不断增加，平台将如履薄冰。欧盟立法机构有意识地拒绝了这一路径——理由充分，因其本质上会架空责任豁免的存在。

在责任框架下，缺乏勤勉意味着平台可能成为他人全部过错的共犯；而在问责框架下，平台仅因未提供某种特定协助而受责。[102] 两种情境下的法律归责性质截然不同，对平台的后果严重性亦大相径庭：承担法律责任的平台面临禁令、连带损害赔偿，并需回应众多因他人行为受害的个体；而仅具问责性的平台仅承受促使其合规的执法压力。前者通过赔偿受害者恢复合法状态，后者则通过调整行为以符合监管期望即可。[103]

若将问责进一步限定为对系统与流程设计及运营中的系统性法律义务，差异更为显著。[104] 在此体系下，若平台违反系统性尽职义务，仅对个体或监管机构负有一项纠正义务；而若该义务嵌入责任豁免，则一次政策执行失败将导致对众多受害者的多重债务。系统性问责意味着向所有受影响者提供一种协助，而连带责任则意味着为众多他人的行为向所有受害者承担全额赔偿——二者天壤之别。此外，DSA 明确禁止对尽职义务违反施加惩罚性赔偿（第 54 条）。

B. 规则的横向性

DSA 与 ECD 设计中隐含的第二项原则是其横向性（horizontality）。横向方

法贯穿整个法律体系，确立了基准性期望。部门性规则仍可能存在，但必须与横向框架互动。在欧盟，DSA 由此成为一部“数字民权宪章”，贯穿整个法律体系，辐射出个体的最低权利保障。除非欧盟立法机构在特定领域明确暂停适用，否则该基准适用于整个用户生成内容服务生态系统。

DSA 不仅延续了责任豁免的横向性，还将其扩展至尽职调查义务。这支持了我此前关于“更新版数字社会契约”的论点。例如，在欧盟体系中，DSA 规则显著改善了若干处理版权问题的部门性规则下的状况。[105]

规则的横向性不仅有利于守法企业和个体，还能防止制度套利。部门性规则若设定不同标准，往往诱发监管套利。例如，在美国，由于 CDA 第 230 条赋予托管服务即使在收到通知后仍享有豁免，各方有强烈动机将各类主张包装为版权问题——因为 DMCA 第 512 条更为宽松。[106] 这导致诽谤索赔被扭曲为版权索赔，长期损害版权政策。当诉因身份模糊、原告可择优选择最有利诉由时，不同法律领域的标准分化必然引发监管套利。唯一避免之道是为所有法律领域采纳一套统一规则。

横向性也有助于更平衡地权衡不同取舍。例如，保护未成年人可能以牺牲成年人自由为代价；仇恨言论执法可能对合法言论产生寒蝉效应。综合性政策使监管机构能更好平衡各方——因其职责覆盖两者。因此，欧盟委员会在评估风险与技术方案时，必须同等考虑仇恨言论的漏检与合法言论的过度屏蔽。鉴于内容审核与风险管理渗透至人类互动的各个领域，尽可能宽广的视野是实现平衡政策的关键。

政治上，横向方法还能缓和某些利益集团的过度影响力，因其拓宽了讨论范围，将其他同样合理的关切纳入其中。《电子商务指令》和《数字服务法》几乎不可能作为部门性措施通过。事实上，美欧经验均表明，在版权这一强游说集团主导的领域，规则不断偏离基准以偏向权利人：DMCA 第 512 条比 CDA 第 230 条更严格；同样，《版权数字单一市场指令》第 17 条也比 DSA 第 6 条更严苛。[107]

C. 责任共担：人人有责

DSA 重申了数字服务中社会风险应由多方共担的民主共识。在“责任共担”原则下，各方都被期待各尽其责——主动保护自身，同时抵制将所有问题归咎于单一行为体的诱惑。

全球责任体系中普遍确立一项原则：若受害者因未尽合理注意而促成自身损害，则本应承担责任的一方将减轻或免除责任。这一比较过失原则早在 1809 年由 Ellenborough 勋爵精辟表述：“一人有过错，不能免除另一人对自己尽到通常

注意的义务。”[10] [9] 可以说，ECD 在其责任豁免设计中即体现了该原则，DSA 的尽职义务亦沿袭此思路。

在责任豁免下，受害者或其代表须向平台通知侵权内容或向主管机关寻求救济，平台则须对通知或官方指令作出回应。平台通常不被要求预防所有个体损害；托管服务商主要在问题被提请注意后才需调查。即使事前风险管理义务亦未改变此基本逻辑。举报非法内容、质疑平台决定、组织协作、学习并教导他人规避风险，仍是 DSA 内容审核体系的核心要素。

责任共担原则的另一体现是 ECD 与 DSA 对一般性监控义务的禁止。原 ECD 第 15 条（现 DSA 第 8 条）规定：

不得对中介服务提供者施加一般性义务，要求其监控其所传输或存储的信息，或主动搜寻表明非法活动的事实或情况。

该条款体现了法律对责任分配的结构性安排：平台不承担普遍干预他人事务的义务。这种隐含分配不仅限于责任豁免，也限制了其他施加于平台的规则（如禁令或国家监管期望）的范围。正如责任豁免体系下负担共担，风险管理体系下的问责亦应如此分配。

责任共担使用户生成内容生态得以繁荣，因其分散了责任与期望。在风险问责框架下，共担同样关键，以避免道德风险。[111] DSA 虽明确将风险问责置于超大型平台（VLOPs/VLOSEs），但并不要求其彻底消除风险——并非所有风险都能以相同方式控制。固有风险无法缓解，而其他风险则可能因平台、用户或第三方行为而加剧。

例如，数字诈骗风险不仅取决于平台防护系统，也取决于用户行为、技能与意识。平台可大力防范，但对用户行为的影响有限。因此风险需合理分配，用户须承担自身部分责任。在多数领域，我们正是如此应对风险——过度保护人们免于自身不负责任，反而可能助长更多不负责任行为。[112] 同理，对虚假信息操纵选举等问题的规制也应以此为起点：VLOPs/VLOSEs 对此类危害负有重大但非绝对、非排他的责任。

这引出了下一项原则。

D. 用户赋权

只有当用户具备能力并被赋予权力去缓解风险时，才能合理要求其分担部分风险。用户赋权原则意味着：用户只能分担那些他们有机会控制的风险。通常，这意味着提供工具，赋予用户决定“看什么、从谁那里看”的自主权。若平台留给用户的自主空间极小，则应承担更多风险；用户获得的自主权越多，越能掌控自身数字体验。因此，无可否认，更多用户赋权意味着平台中心责任的减少——这

或许不为所有人所乐见，但并不意味着平台可借此推卸所有风险责任；若与对用户的合理期望相结合，赋予用户的控制权最多只能减轻其责任。

DSA 试图赋予用户对其体验的新控制杠杆，例如：挑战平台决定、就审核错误获得补偿、在平台前获得代表、使用新的家长控制工具，以及对推荐系统拥有选择权。正如 DSA 序言第 40 条所述，尽职义务应旨在：[113]

特别保障若干公共政策目标，如服务接收者的安全与信任……《宪章》所载相关基本权利的保护、提供者的实质性问责，以及接收者与其他受影响方的赋权，同时便利主管机关的必要监督。

因此，个体赋权已内嵌于 DSA，并鼓励平台善用其力量。对 VLOPs/VLOSEs 而言，权衡清晰：交出部分控制权以换取较低风险责任，或保留全面控制并承担更多平台内发生之事的责任。风险共担由此成为激励平台向用户授权、增强其作为具有自由意志与偏好的个体之能动性的机制。

此处所指“赋权工具”并非显而易见的基础功能。现实中，所有平台都给予用户一定程度的数字体验自主权——我们都希望按偏好关注他人，屏蔽逾越个人底线者。[114] 然而，平台仍在许多用户偏好本可合法分歧的决策上保有过多中心控制。这在涉及“合法但具争议性内容”的托管时尤为关键。尽管用户对商业垃圾信息的偏好趋同，但对令人震惊、耸人听闻、裸露或粗俗内容的敏感度却千差万别。

学界如 Fukuyama 等人曾主张通过“中间件”（middleware）工具系统实现赋权，让用户个性化其内容审核体验。[115] 多中心内容审核（polycentric content moderation）的理念——将更多决策权交予用户——实际上已然存在，但在 DSA 之前无法通过法律强制推行。设想一家名为 TrollWall 的新创公司[116]，为社交媒体页面管理员提供基于机器学习的内容审核工具，旨在解决 Facebook 非法内容移除缓慢的问题，同时提供可扩展方案以维护在线讨论的文明。该工具允许管理员调整内容类别、敏感度及对检测内容的处理方式。尽管该工具由第三方提供给页面管理员[117]，但 Facebook 在创建支持该工具的 API 并批准其在平台分发方面扮演关键角色。尽管该工具远非完美，却赋予管理员更大能动性，以应对人力监督无法企及的规模问题。DSA 可为更多此类将控制权交予用户及个体的工具铺平道路。

E. 生态系统解决方案

若社会挑战的责任由多方共担，则每个人都需成为解决方案的一部分。在平台与国家各自履行角色的同时，公民社会则对二者进行问责。

打击极端主义或虚假信息，唯有在平台获得生态系统中多方行动者协助时方能成功——如可信的非政府组织（负责举报内容）、事实核查员、记者或研究人

员。第一代规则（如 DMCA、CDA、ECD）的一大缺陷在于过度聚焦平台，几乎忽视生态系统中其他参与者。[118] 在《电子商务指令》下，仅平台获得责任豁免，而参与解决社会挑战的其他方未获任何专门工具。欧盟曾寄望自律机制解决此问题，但这常导致不同服务间安排参差不齐，且可能因平台新所有者或管理层更迭而被随意剥夺。[119] 对公民社会而言，这种差异意味着难以规模化响应。

DSA 将生态系统置于核心位置。它承认内容审核是平台决策的产物，但其质量同样依赖于输入（通知质量）与反馈（用户纠正错误的能力）。

在输入端，DSA 试图激励高质量通知。平台须以用户友好方式设计提交界面以协助其他行动者。[120] 对有良好记录的“可信举报者”（trusted flaggers）给予优先处理。[121] 滥用地位的可信举报者可能被监管机构暂停资格或撤销认证。[122] 平台须暂停或终止反复提交滥用通知或明显非法内容者的账户。[123] DSA 鼓励通知交换的标准化，[124] 以推动跨平台自动化解决方案的出现。

在反馈端，DSA 试图减少平台与内容创作者之间的信息不对称。平台须事先充分披露其规则，并说明所用自动化工具。[125] 对广泛类型的内容审核决定，须提供个别化解释，并允许免费申诉。[126] 若内容创作者或举报者不满，可向庭外争议解决机构提起外部申诉。[127] 若平台败诉，须承担申诉方启动外部申诉的费用，以激励其内部提升决策质量。[128] 专业组织可参与争议解决过程，帮助内容创作者提升代理质量。[129] 消费者团体可提起集体禁令救济，以纠正不合规行为。[130]

在风险管理支柱下，DSA 要求研究人员、公民社会与审计机构共同识别相关风险并发明新的缓解方法。对最大型数字服务，监管机构公开就社会挑战展开监管对话，以强化审查。

换言之，DSA 为数字生态系统中的其他行动者提供了可在保护私人或公共利益时依赖的工具。通过此举，DSA 高度依赖法律只能预见和激励、却无法构建的社会结构——如分析威胁的地方组织、协助内容创作者的消费者团体、研究者社群等。正是这些结构赋予 DSA 工具生命力。它们需由民众自下而上构建，甚至可能在每个成员国本地发展。若这些结构未能建立，监管承诺恐将沦为华而不实的空想。

V. 结论

截至 2023 年，内容审核在美国依然是一个政治上存在分歧的话题。共和党倾向于减少对未被立法机关禁止的内容的审核，而民主党则希望增加对此类内容的审核力度。尽管欧洲的政治局势也在演变，但尚未像美国那样受到同样的影响。虽然双方在如何行使内容审核裁量权方面无法达成一致，但至少可以同意重新引

入事先编辑审查的立法并不符合任何一方的利益。

互联网作为一种特殊的媒介，不应像广播或报纸那样进行监管。只有当提供商对他人的内容分发承担非常有限的责任时，内容审核裁量权才能存在。如果责任是严格或近乎严格的，那么这种裁量权必须转变为编辑裁量权，因为在没有预先审查信息的情况下，没有人能够提供数字空间或表达工具。

基于编辑控制基础设施运行我们的数字服务——从社交媒体和市场到搜索引擎——是不可能的。因此，政策制定者的目标应该是提高提供商的问责性，同时保持其责任有限。平台需要更多的问责性，而不是责任。它们的设计实践应受到监管，但这并不意味着立即扩展基础内容法律。（*作者的观点是呼吁更多的行政监管，而不是民事责任。*）

由于非编辑内容缺乏编辑，有人认为它也将永远缺乏信任。这促使政策制定者推动更严格的内容标准，甚至要求编辑裁量权。然而，有办法在不放弃去中心化特征的情况下向生态系统注入信任。例如，“可信内容创作者”（Trusted Content Creators, TCC）解决方案完全基于责任共担和生态系统解决方案的原则。TCC 不是禁止或压制不可信的内容，而是通过让提供商为那些自我组织并承诺遵守共同规范的内容创作者提供额外福利来奖励可信内容。去中心化并不是信任的对立面。

同样地，有许多方法可以克服关于如何对合法内容行使内容审核裁量权的不同观点。“用户赋权”原则为解决两种立场之间的中庸之道指明了方向。它鼓励政策制定者思考将显示什么合法内容的选择从广告商或提供商转移到个人的解决方案。立法机构也可以通过使基础市场更具竞争力或开放主导服务中的内容审核体验以容纳更多选择来促进用户选择。

人们用脚投票表明他们对非编辑内容的兴趣远大于对编辑内容的兴趣。在全球访问量最大的 50 个网站中，绝大多数依赖于用户——其他人——生成内容。看起来人类主要对其他人类要说的话感兴趣。没人能比得上人群教育和娱乐的力量。虽然我们经常担心此类内容的合法性和可信度问题，但只有少数人认为解决方案是回到编辑媒体的时代。

提出的五项原则为自由民主国家提供了共同的基础，以思考当今的挑战，而不牺牲我们已经获得的东西：一个包容、去中心化且开放的全球通信网络。